

1500375-52.2021.8.26.0272

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: VANESSA APARECIDA BUENO

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006). Condenação. 3. Alegação de cerceamento de defesa. Suposta nulidade absoluta em razão da não apreciação de pedido de reaperguntas ao corrêu. Inocorrência. A condenação está amparada em amplo contexto probatório ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

1ª Vara

Praça Coronel Souza Ferreira, s/nº, . - centro

CEP: 13970-906 - Itapira - SP

Telefone: (19) 3863-0523 - E-mail: itapira1@tjsp.jus.br

1500375-52.2021.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500375-52.2021.8.26.0272

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

OTHON HENRIQUE DUARTE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

OTHON HENRIQUE DUARTE, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso no art. 33, "caput" c.c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, porque, segundo a denúncia, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 6h30min, na Rua São José, nº 103, Bairro Jardim Salgado, nesta cidade e Comarca de Itapira, juntamente com seu irmão e adolescente E. T. D, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 120 (cento e vinte) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos individuais, com peso total aproximado de 207,0g (duzentos e sete gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 06 e laudo de exame químico toxicológico (fls. 110/112).

O acusado foi preso em flagrante no dia 26.04.2021 (fls. 01/16). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 57/61).

Notificado (fl. 108), o acusado apresentou defesa preliminar (fls. 123/131).

A denúncia foi recebida em 12.08.2021 (fls. 138/140) e o acusado foi citado (fl. 167).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, realizada por videoconferência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o acusado interrogado. A audiência foi gravada em nuvem e disponibilizada às partes pelo Portal e-SAJ no sítio do TJSP na internet (fls. 182/183 e 196/197).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, em preliminar, pugnou pela nulidade do feito pela inépcia da denúncia por falta das fórmulas ou termos legais para o regular exercício da ação penal, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requereu a absolvição do acusado por não ter ele praticado a infração penal e ou por insuficiência de provas, sustentando que o irmão dele, Ethory, ouvido em juízo, admitiu que as drogas seriam de propriedade dele e não do acusado. Em caso de condenação, requereu o reconhecimento da atenuante da menoridade, a aplicação do tráfico privilegiado em razão da ausência de antecedentes criminais do acusado e a substituição por pena restritiva de direito (fls. 198/206).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, anoto que a preliminar de inépcia da denúncia foi alvo de rejeição por este juízo na decisão que recebeu a denúncia às fls. 138/140, a cujos fundamentos me reporto nesta oportunidade para uma vez mais rejeitá-la.

No mérito, a denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade do crime imputado ao acusado está satisfatoriamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/16), boletim de ocorrência policial (fls. 03/05), auto de constatação (fl. 06), auto de exibição e apreensão (fl. 10), mandado de busca e apreensão domiciliar (fls. 24/27), laudo toxicológico definitivo (fls. 110/112) e pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e se acha devidamente provada nos autos.

Com efeito, ouvida em juízo, a policial civil Ligia Petri Geraldino, após ser indagada, narrou que, na data dos fatos, dirigiram-se até a residência do acusado para cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido por conta de diversas denúncias pelo "disk Denúncia" de que naquele local estariam sendo guardadas diversas motocicletas roubadas. Contou que a mãe do acusado atendeu a porta e permitiu o acesso na casa. Em seguida, foram até o quarto onde o acusado e o irmão dele estavam dormindo e foram localizados cento e vinte pinos de cocaína. Indagada, respondeu que tanto o acusado quanto Ethory, irmão dele, estavam dormindo naquele mesmo quarto. Indagada, respondeu que os acusados são bastante conhecidos tanto pela prática do tráfico de drogas quanto pelo roubo de motos. Indagada, respondeu que Ethory possui bastante atos infracionais e acredita que o acusado também tenha tido. Indagada, respondeu que os acusados foram indagados se no local havia droga e ambos negaram. Ao serem localizadas as porções no interior de um armário, ambos foram novamente indagados e silenciaram-se nesse momento. Indagada, respondeu que no local da apreensão das drogas foi apreendido um aparelho celular que pertenceria ao menor Ethory e não foi apreendida importância em dinheiro. Indagada, respondeu que o celular foi apreendido para realização de perícia, desconhecendo se foi realizada (fls. 182/183).

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Carlos Alberto Verdeli, que, em juízo, ratificou a versão apresentada pela testemunha Ligia, salientando que em cumprimento de mandado de busca na residência do acusado foram localizados os entorpecentes em um armário no quarto do acusado. Disse que o acusado e o irmão dele eram conhecidos dos meios policiais e estavam no encalço deles por conta de outras investigações sobre tráfico de drogas e roubo de motocicletas devido a diversas denúncias pelo "Disk Denúncia". Acrescentou que, por conta disso, foi solicitado o mandado de busca para a residência do acusado. Indagado, respondeu que, após a localização dos entorpecentes, o acusado imediatamente afirmou que as drogas pertenceriam a ele e não ao irmão dele. Indagado, respondeu que não havia denúncia anônima de tráfico de drogas exclusivamente pelo nome do acusado, havendo, no entanto, indicação da prática desse crime no endereço residencial dele, Rua São José, 103. Indagado, respondeu que o celular foi apreendido e segundo consta ele pertenceria ao Otho (fls. 182/183).

A testemunha de defesa Ethory Turese Duarte, irmão do acusado, narrou que a droga apreendida no dia dos fatos lhe pertencia e que ela foi localizada no interior de seu quarto, esclarecendo que o quarto do acusado, seu irmão, fica ao lado do seu. Acrescentou que os policiais teriam “forjado” em seu irmão e o levaram para a delegacia. Toda a droga apreendida era sua. Indagada, respondeu que usaria uma parte do entorpecente e que venderia o restante. O celular apreendido no local também lhe pertencia. Indagada, respondeu que na época dos fatos era menor de idade. Atualmente, encontra-se na Fundação Casa em razão dos fatos ocorridos nos presentes autos (fls. 196/197).

Interrogado judicialmente, o acusado negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos em sua residência. O quarto onde foram encontradas as drogas era de seu irmão. Nesse quarto, somente seu irmão dormia nele. Indagado, respondeu que já respondeu por tráfico quando era menor de idade. Não tinha ciência da existência de drogas no quarto de seu irmão. Indagado acerca das declarações que prestou à fl. 13, afirmou que esse depoimento era de seu irmão. Indagado se conhece o Sr. Anderson Cassimiro de Lima e o Sr. Luciano Cordeiro Botelho, respondeu que não e afirmou que nada tem contra essas pessoas. Também não conhece e nada tem contra as pessoas de Carlos Alberto Verdelli e Ligia Petri Geraldino (fls. 196/197).

Em que pese a negativa do acusado, sua versão, de que a droga encontrada em seu quarto em sua residência pertenceria ao seu irmão Ethory, restou dissociada dos elementos de prova constantes nos autos, notadamente a prova oral, consistente nos depoimentos prestados em juízo pelas autoridades policiais, plenamente coesos e harmônicos entre si, inexistindo dúvidas, portanto, acerca da autoria delitiva. Segundo os relatos dos policiais em juízo, haviam diversas denúncias anônimas dando conta da prática do crime de tráfico de drogas e roubo de motocicletas pelo acusado e pelo irmão dele Ethory.

Em que pese a testemunha Ethory tenha afirmado em juízo que as drogas apreendidas na residência dos fatos lhe pertenciam e que o acusado, no momento da diligência policial, estaria dormindo em seu próprio quarto, a policial Ligia foi taxativa em afirmar em juízo que tanto o acusado quanto Ethory estavam dormindo no mesmo quarto no momento em que se dera a busca e a consequente locação das drogas mantidas no interior de um armário.

Vale anotar que, segundo o policial Carlos Alberto, assim que as drogas foram localizadas, o acusado de imediato teria admitido a propriedade delas, na tentativa de isentar seu irmão Ethory, atualmente recolhido na Fundação Casa por conta do presente caso, conforme, aliás, ele próprio informou em seu depoimento em juízo. Daí que, como se vê, ambos os irmãos tentam isentar um ao outro da responsabilidade penal.

Com efeito, os depoimentos das autoridades policiais merecem credibilidade. Por ser tratarem de agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e devem ser acolhidas sem reserva. Além disso, não há razão plausível para colocar sob suspeita o relato de agentes públicos legitimados para o combate ao crime simplesmente em razão de sua condição.

Ademais, a Defesa não logrou demonstrar que as autoridades policiais ouvidas sob o crivo do contraditório foram parciais ou nutriram interesse em prejudicá-lo, de modo que os seus testemunhos se mostram imaculados e, por isso, constituem meio idôneo de prova.

Destaca-se que o próprio acusado, em seu interrogatório, após ser indagado se teria alguma coisa contra os policiais que realizaram a diligência e os que lavraram a sua prisão em flagrante, afirmou que nada tem contra eles.

Logo, se não há indicação de vício nos relatos apresentados, é plenamente possível sua utilização para fundamentar a sentença condenatória, valendo anotar que o simples fato de a testemunha ser policial não pode jamais servir para desacreditá-la.

A propósito, assim se firmou a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado, mormente em hipótese como a dos autos, em que os depoimentos foram corroborados pelo

conteúdo das interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais corréus.

3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ" (HC 393.516/MG, j. 20/06/2017).

Também o Supremo Tribunal Federal - ainda que indiretamente - admitiu a validade do depoimento de policiais para fundamentar a condenação:

"Agravos regimentais em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006). Condenação. 3. Alegação de cerceamento de defesa. Suposta nulidade absoluta em razão da não apreciação de pedido de repurgação ao corréu. Inocorrência. A condenação está amparada em amplo contexto probatório produzido durante a instrução, sobretudo em depoimentos dos policiais que prenderam o recorrente em flagrante e em monitoramento telefônico. A sentença não fez referência à confissão do corréu para fundamentar o juízo condenatório do acusado.

4. Agravos regimentais a que se nega provimento" (RHC 123731 AgR/SP, j. 31/05/2016). Tal conclusão é endossada pelo fato de a Defesa não ter produzido qualquer prova da suspeição ou impedimento dos referidos agentes públicos, apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do art. 156, "caput", do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

"PROVA. Defesa fundamentada em fato singular. Ônus da prova. Cabe ao acusado que fundamenta defesa em fato singular e contrário ao que normalmente ocorre em circunstâncias semelhantes, o ônus da prova do argumento." (JUTACRIM 54/243, Rel. VALENTIM SILVA).

Não se perde de vista ainda que as autoridades policiais notificaram o recebimento da notícia anônima e que logo em seguida trataram de investigar o fato criminoso indicado com trabalho de campo exitoso, inclusive levando ao crivo do Poder Judiciário, que autorizou a expedição de mandado para realização de busca e apreensão na residência dos fatos.

Aliás, tem-se decidido que:

"nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados" (STF; HC 105.484/MT, Rel. Min. Carmen Lúcia); e, ainda no Supremo Tribunal Federal, HC-RO 120.787/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

Com efeito, a partir das circunstâncias previstas no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, ora referidas e provadas, é possível concluir, com o necessário grau de certeza, que o acusado estava praticando tráfico de drogas. Dito de outro modo, as circunstâncias do caso não permitem admitir que as drogas encontradas com ele destinavam-se ao consumo pessoal.

As drogas apreendidas (120 porções de cocaína), a constatação da veracidade da delação anônima recebida pela Polícia Civil por meio do "Disk Denúncia", dando conta de que o acusado e o irmão dele estariam armazenando coisas ilícitas na residência dos fatos, igualmente indicada nas denúncias, e as demais circunstâncias em que se deram a prisão indicam, conclusivamente, que o acusado se dedicava mesmo à traficância.

Não é demasiado enfatizar, em consonância com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que, como no caso dos autos, o acusado estivesse simplesmente guardando ou tendo em depósito as drogas para que reste caracterizado o crime, não se exigindo a prática de atos de mercancia para a sua configuração.

Neste sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido." (RT 729/542).

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização". (RT 714/357).

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente". (RT 776/663). Inviável, por conseguinte, a desclassificação do delito para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

A Defesa não logrou provar o contrário.

Assim, impõe-se a condenação do acusado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não deve ser reconhecido em favor do acusado, haja vista que a quantidade das drogas apreendidas em seu poder, ou seja, 120 porções de cocaína, já devidamente embaladas para a venda, a denúncia anônima previamente recebida dando conta da existência de material ilícito na residência do acusado, demonstra que não se trata de traficante eventual e que fazia do tráfico o seu meio de vida, assertiva esta é reforçada do fato de o acusado não ter comprovado o alegado trabalho na época dos fatos. Não se pode perder de vista também que processos perante o Juízo da Infância e Juventude (cf. fls. 44/45) não caracterizam maus antecedentes, mas, por outro lado, podem caracterizar a dedicação do acusado a atividades criminosas desde longa data e afastar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

"Embora atos infracionais não possam ser considerados como maus antecedentes e nem se prestem para induzir a reincidência, inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 quando demonstrado que a paciente praticou, de forma reiterada, diversos atos infracionais, inclusive relacionados ao tráfico de entorpecentes, vez que tais elementos 'servem para demonstrar a propensão da agente ao cometimento de delitos dessa natureza' e a sua dedicação a atividades criminosas, deixando de preencher um dos requisitos legais para a incidência do benefício" (STJ, HC 121509/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJe 29/03/2010).

Em outra oportunidade:

"Esta Corte é uníssona no sentido de que atos infracionais anteriores não podem ser sopesados na apuração de maus antecedentes para elevar a pena-base, tampouco para induzir a reincidência, entretanto, tem evoluído, entendendo que os antecedentes infracionais podem indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas. Precedentes. 4. Desde que devidamente comprovado, o envolvimento reiterado do paciente, quando menor, em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas" (STJ, HC 299.673/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/08/2016).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça vem afirmando, repetidamente, que é legítimo afastar o benefício acima, mesmo em sendo o acusado primário, quando expressiva a quantidade ou natureza da droga apreendida:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 1. Esta Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em poder do acusado constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de

diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta. (...)” (STJ, AgRg no REsp: 1302590 RS 2012/0016349-7, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j. 11/03/2014, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2014).

Finalmente, reconheço a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, vez que, conforme as provas dos autos, o acusado praticou o crime de tráfico de drogas valendo-se do auxílio do seu próprio irmão, E. T. D., cuja menoridade está suficientemente comprovada nos autos (fl. 15). Note-se que foram colhidos elementos que deixam absolutamente indubitado o envolvimento do menor no tráfico, como dimana dos depoimentos testemunhais já transcritos. Destarte, para efeito de caracterização da circunstância do inciso VI do citado artigo 40, a prova do envolvimento de adolescente é, nos presentes autos, firme e bastante convincente.

Por isso tudo, inarredável o reconhecimento do tráfico hediondo e a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, em razão do que passo a dosar as penas aplicáveis.

Na primeira fase da dosimetria, em observância ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece as circunstâncias judiciais preponderantes, anoto ser desfavorável a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendido na posse do acusado, ou seja, 120 porções de cocaína, de elevadíssimo grau destrutivo para as pessoas e para a sociedade.

A propósito:

“O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada.” (STJ - HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe. 15.03.2012).

Assim, por conta dessa circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Por outro lado, em razão da menoridade relativa do acusado na época dos fatos, reduzo a reprimenda intermediária ao mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena. No entanto, verifica-se presente a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. Em razão dela, elevo a reprimenda em 1/6, tornando definitiva a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Como não há elementos sobre as condições econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Como se cuida de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90) e considerando o quanto da pena aplicado, impõe-se a fixação do regime fechado para o início da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º e 3º, do Código Penal, que reputo ser o mais adequado e suficiente ao caráter preventivo e repressivo da reprimenda.

A propósito:

“No concernente ao regime prisional impositivo à espécie, também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei nº 11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da instituição familiar” (TJSP, Apelação nº 0011111-

87.2008.8.26.0361, 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel: Des. Paulo Rossi, j. 1º/07/2009) (destaquei)

Anoto, ainda, a impossibilidade de aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A aplicação deste dispositivo carece de melhor regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento tão somente no tempo de custódia cautelar, o juízo do processo de conhecimento necessitaria ter acesso a dados pessoais da acusada, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui, além do requisito objetivo, o subjetivo. Tal análise, a meu ver, deve ser feita no âmbito da execução penal. Consigno que o desconto imposto pela legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas. Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo da Execução.

A propósito:

“E no tocante a aplicação do contido no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observa-se que detração de pena se trata de matéria cuja apreciação é de competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em legislação especial, específica, não obstante relativamente recente reforma parcial do Estatuto Adjetivo tenha estabelecido a matéria no artigo em comento. Nem poderia ser diferente, uma vez que apenas o MM. Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de condenações do embargante, aí incluídas todas as suas eventuais execuções, como também o seu histórico comportamental, na condição de detento” (TJSP, Embargos de declaração nº 0005822- 97.2007.826.0624/50000, rel. Des. Marco Antônio Cogan, J. 05/09/2013).

Inviável, ademais, a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, pois é medida insuficiente para a prevenção do abjeto comércio que se difunde e fomenta a delinquência no país, sendo imperiosa a manutenção da pena privativa de liberdade. Pelas mesmas razões, também é incabível o “sursis”.

Finalmente, veda-se ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, sendo a prisão preventiva necessária para manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, máxime em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso concreto, muito especialmente para evitar a reiteração criminosa.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado OTHO HENRIQUE DUARTE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, de valor unitário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos das NSCGJ, recomende-se a prisão do acusado em presídio adequado ao regime prisional fixado nesta sentença. Expeça-se o necessário.

Como não houve controvérsia acerca da natureza e quantidade da droga apreendida, DETERMINO a sua destruição, caso já não tenha sido realizada, observadas as cautelas previstas nos arts. 50, §§ 4º e 5º, da Lei de Drogas.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, ressalvada eventual inexigibilidade a ser aferida em sede de execução.

Se for o caso, expeça-se, oportunamente, certidão de honorários ao Defensor eventualmente nomeado ao acusado, nos termos da tabela do convênio entre a DPE/OAB. P.I.

Itapira, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA